

1501298-47.2020.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARISE TERRA PINTO BOURGOGNE DE ALMEIDA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... estreito envolvimento do réu Kauan com o tráfico já que nenhum iniciante nesta atividade criminosa receberia tamanha quantidade para guardar ou apenas consumir. Por conseguinte, Kauan não pode ser considerado traficante eventual ou de pequeno porte, razão pela qual deve ser afastado o tráfico privilegiado.

Em relação a Wilson, considerando que não demonstrada sua relação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

5ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501298-47.2020.8.26.0617 - Controle nº 2020/000773

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

KAUAN EDUARDO VILELA RODRIGUES e outro

Juíza de Direito: Dra. Marise Terra Pinto Bourgogne de Almeida

Vistos.

KAUAN EDUARDO VILELA RODRIGUES e WILSON MORENO JUNIOR, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso, o primeiro, nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e do artigo 33, § 1.º, inciso II, da Lei nº 11.343/06, e o segundo nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque, no dia 13 de outubro de 2020, por volta das 13h00min, na Rua Vicente Cardoso nº 65, no Jardim Torção de Ouro, nesta cidade e Comarca, KAUAN EDUARDO VILELA RODRIGUES teria sido surpreendido por policiais militares preparando e tendo em depósito, para fins de comércio e consumo de terceiros, 381,95 g (trezentos e oitenta e um gramas e noventa e cinco centigramas) da droga Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, conforme laudo de constatação provisória, juntado a fls. 65/69, e Laudo de Exame Químico Toxicológico (itens 4, 6 e 8), juntado a fls. 188/191, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; guardando, para fins de preparo, comércio e consumo de terceiros, um frasco plástico contendo 2,10 g (dois gramas e dez centigramas) da droga vulgarmente conhecida como "ecstasy" (MDA - μ -Metil-3,4-(Metilendioxi)Fenetilamina), na forma de pó, conforme laudo de constatação provisória, juntado a fls. 65/69, e Laudo de Exame Químico Toxicológico, juntado a

fls. 188/191, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; trazendo consigo, para fins de preparo, comércio e consumo de terceiros, um saco plástico com 40,06 g (quarenta gramas e seis centigramas) da droga vulgarmente conhecida como "ecstasy" (MDA - μ -Metil-3,4-(Metilendioxi)Fenetilamina), na forma de pó, conforme laudo de constatação provisória, juntado a fls. 65/69, e Laudo de Exame Químico Toxicológico, juntado a fls. 188/191, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, e semeando e cultivando plantas que constituem matéria-prima para a preparação de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta ainda do incluso inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de local já mencionadas, nesta cidade e Comarca, WILSON MORENO JÚNIOR, teria sido surpreendido por policiais militares trazendo consigo, com a finalidade de vender a terceiros para consumo, 7,47 g (sete gramas e quarenta e sete centigramas) da droga vulgarmente conhecida como "ecstasy" (MDA μ -Metil-3,4-(Metilendioxi)Fenetilamina), na forma de comprimidos (20 unidades), conforme laudo de constatação provisória, juntado a fls. 65/69, e Laudo de Exame Químico Toxicológico, juntado a fls.

188/191, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; e guardando, com a finalidade de vender a terceiros para consumo, 1,47 g (um grama e quarenta e sete centigramas) da droga vulgarmente conhecida como "ecstasy" (MDMA - 3,4-metilenodioximetanfe-tamina), na forma de comprimidos (04 unidades), conforme laudo de constatação provisória, juntado a fls. 65/69, e Laudo de Exame Químico Toxicológico), juntado a fls. 188/191, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado Wilson em primeiro grau (fls. 234/236), fora concedida a ordem em pedido de habeas corpus com determinação de revogação da prisão preventiva dos réus (fls. 255/257).

Cumpridos os alvarás de soltura (fls. 264/266 - réu Wilson; fls. 269/271 - réu Kauan), Kauan não foi localizado para ser notificado pessoalmente (fls. 319), razão pela qual foi notificado por edital (fls. 325). O acusado Wilson foi notificado pessoalmente (fls. 338).

Houve apresentação de defesa preliminar pelos réus (fls. 349/356 - Wilson e fls. 358/359 - Kauan), e, ante a constituição de Advogado pelo réu Kauan, ele foi dado por notificado na pessoa de seu patrono, sendo a denúncia recebida, conforme decisão de fls. 365/367.

O réu Kauan não foi localizado para citação pessoal (fls. 392); o réu Wilson foi pessoalmente citado e intimado da audiência (fls. 413).

Em audiência de instrução e julgamento, o réu Kauan foi considerado citado. Ainda, foram ouvidas as testemunhas pelas partes.

Deferido prazo para juntada de declarações e fotografias requeridas pela Defesa do réu Wilson, após, em audiência, os réus foram interrogados.

Encerrada a fase instrutória, o D. Representante do Ministério Público, em memoriais, pugnou pela condenação dos acusados nos termos da inicial, sem qualquer benefício na aplicação da pena, especialmente ante a quantidade e variedade das drogas apreendidas, além das circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante, demonstrando não serem os acusados traficantes ocasionais (fls. 507/538).

A Defesa do réu Kauan requereu a absolvição por insuficiência de provas no tocante ao delito de tráfico, requerendo a desclassificação para o tipo penal previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06, pelo fato de o acusado ser usuário de drogas, além de ter comprovado atividade laboral. Alega nulidade em razão de prova ilícita obtida por meio dos depoimentos dos policiais militares, em razão de invasão de domicílio e quebra de sigilo telefônico. Alternativamente, requereu a aplicação do benefício previsto no § 4.º do artigo 33 da Lei de Drogas, bem como regime mais brando para início de cumprimento de pena, com substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mormente em face da primariedade do réu, bem como recurso em liberdade (fls. 542/549).

No mesmo sentido, a Defesa do réu Wilson, em memoriais, requereu, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade em razão de prova ilícita, eis que os policiais militares invadiram o domicílio do corréu Kauan. Ademais, com relação a Wilson, alega que o flagrante foi preparado, pois os policiais verificaram, a partir do

telefone celular de Kauan, que ele iria chegar no local onde já se encontravam. Ademais, o acusado Wilson adentrou a residência mesmo vendo a viatura policial em frente à casa de Kauan. Quanto ao mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, com aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas. Alternativamente, requereu a aplicação do benefício previsto no § 4.º do artigo 33 da Lei de Drogas, bem como substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além de regime mais brando para início de cumprimento de pena e recurso em liberdade. Pugnou, por fim, pela restituição do veículo apreendido com Wilson e seu aparelho de telefonia celular (fls. 550/566).

Relatado.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, não há se falar em nulidade do feito em razão da ilicitude da prova face à invasão de domicílio do acusado Kauan.

Isso porque, conforme decisão do C. Superior Tribunal de Justiça, é admissível que policiais adentrem residência quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca de ocorrência de crime no interior desta casa, sem que se caracterize invasão ao domicílio (HC 608.558/RJ).

Justamente este o caso dos autos, pois os policiais militares Maurício e Rodrigo receberam denúncias de que no endereço do acusado Kauan ocorria venda de drogas com grande movimentação de pessoas. Ao se dirigirem ao logradouro, encontraram um indivíduo em atitude suspeita em frente à residência, o que ocasionou a abordagem. O indivíduo foi identificado como o acusado Kauan e, em revista pessoal, de fato havia droga com ele, confirmando sua atitude suspeita. Somente após esta circunstância é que adentraram a residência e confirmaram a denúncia recebida, eis que se depararam com grande quantia de drogas no local.

Desta feita, não há se falar em nulidade por ser a prova ilícita.

No tocante ao alegado flagrante preparado em relação ao corréu Wilson, trata-se de preliminar que se confunde com o mérito, e com ele será analisado.

Quanto ao mérito, a materialidade delitiva está bem provada, conforme auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (fls. 02/05), auto de exibição e apreensão (fls. 09/11), imagens fotográficas (fls. 30/63), laudo de constatação provisória (fls. 65/69), laudo pericial (fls. 177/187), laudo de exame químico-toxicológico de fls. 188/191, com resultado positivo para conhecidas como "ecstasy" e maconha, sendo no mesmo sentido o laudo pericial de fls. 428/430, além das demais provas colhidas, especialmente sob o crivo do contraditório.

A autoria é indubitosa em relação aos acusados.

Interrogado na fase policial, o acusado Kauan permaneceu silente (fls. 15).

Em juízo, negou a traficância. Alegou que realmente plantava as drogas para uso próprio e para não precisar ir a biqueira adquirir. Montou estufa com itens caseiros e que havia comprado pela internet. Quanto a outras drogas, como "MD", que é uma droga sintética, também era para seu uso próprio, especialmente neste momento de pandemia. Disse que sua abordagem se deu com a entrada de policiais em sua residência, sem sua autorização. Negou que estivesse em uma moto. Wilson chegou depois, com drogas também, que acredita ser "ecstasy". A maconha em seu quarto não estava embalada individualmente. Wilson era seu amigo. Sua intenção era não contribuir com o tráfico de drogas, mas a droga sintética ele comprou. Kauan estava de folga naquele período. Foram dois policiais que estiveram em sua casa, a princípio. Depois, chegaram mais quatro ou cinco policiais. Na abordagem policial, os milicianos pediram que Kauan desbloqueasse seu celular e viram uma mensagem de que tinha alguém para chegar no local. Sua moto ficava na rua, pois não tinha garagem. Disse que sua residência tem um portão no meio, que fica aberto. A viatura estava em frente à sua casa, mas no momento de sua abordagem não viu onde ela se encontrava. Wilson entrou e viu a movimentação de policiais. Não soube como foi a abordagem em Wilson. A "estufa" utilizada para o cultivo da droga era seu guarda-roupas, algo precário. Não teve auxílio de ninguém para o cultivo da droga e nunca ofereceu pra ninguém. Não chegou a produzir em grande escala e ele estava apenas fazendo testes.

Na fase policial, o acusado Wilson, ao ser interrogado, alegou residir na cidade de

São Paulo, porém, na data dos fatos, veio até a casa de seu amigo, Kauan, pois no dia seguinte iria para o litoral. Quanto aos 24 (vinte e quatro) comprimidos de "ecstasy" apreendidos, alegou que todos lhe pertenciam e se destinavam ao seu consumo. Negou o comércio das drogas, pois chega a tomar até 06 (seis) comprimidos da droga em uma única noite e, como pretendia "sair" nesta cidade de São José dos Campos e no litoral, adquiriu os comprimidos com um desconhecido, que havia encontrado em uma festa anteriormente. Por fim, sobre os entorpecentes apreendidos na casa de Kauan, nada disse, pois, até a data dos fatos, tinha conhecimento apenas que Kauan era usuário de drogas (fls. 21).

Em juízo, o acusado tornou a negar a prática delitiva. Disse, ainda, que ao chegar na casa de Kauan e chamar por ele, sem que ele respondesse, resolveu entrar. Na cozinha, já se deparou com um policial armado que o revistou e encontrou os comprimidos de "ecstasy" que estavam consigo. Este policial solicitou apoio e vários outros policiais chegaram ao local e perguntavam se havia mais droga ou outras pessoas envolvidas, além de armas. Os policiais disseram que se eles tivessem arma ou mais drogas, poderiam ser liberados. Wilson deu a chave de seu carro a um policial. Posteriormente, outro policial localizou mais droga em seu veículo, tendo o réu dito que também se destinava ao seu uso. Kauan não tinha feito encomenda para ele de droga. Wilson sabia que Kauan usava maconha. Ao chegar na residência, o interrogando disse que não viu viatura em frente à casa de Kauan. A residência de Kauan tem muro baixo e o portão estava aberto. Ele mandou mensagem para Kauan, ao que ele pediu para entrar. Não tinha costume de frequentar a casa de Kauan, mas já tinham saído juntos. Durante a abordagem policial, ficaram juntos no quarto. Não houve troca de mensagens no celular falando sobre drogas. Não foi recebido por ninguém, mas ao adentrar a residência, deparou-se com um policial na cozinha da casa. Não havia viatura estacionada em frente à casa do acusado. Em nenhum momento o acusado ofereceu comprimidos para venda ao acusado Kauan. Tinha pago nos comprimidos a quantia de R\$600,00 (seiscentos reais). É formado em engenharia mecânica, com pós graduação e, atualmente, é corretor. Chegou a ver pé de maconha no armário da casa de Kauan. Faz uso de "ecstasy" há cerca de cinco anos. Adquiriu sua droga em São Paulo.

As versões dos acusados, especialmente sob o crivo do contraditório, não podem ser acolhidas, pois desprovidas de credibilidade e dissonantes das demais provas dos autos.

Com efeito, os policiais militares Maurício e Rodrigo, ouvidos nas duas fases do procedimento, narraram que receberam denúncias de que, no local dos fatos, estava ocorrendo venda de drogas com grande movimentação de pessoas. Diante disso, em diligências pelo bairro Torrão de Ouro, avistaram um indivíduo suspeito, identificado posteriormente como o ora acusado Kauan Eduardo, que descia de uma motocicleta modelo Suzuki/Yes, de cor prata, em frente da residência de numeral 65, na Rua Vicente Cardoso. Os policiais realizaram a abordagem e, em revista pessoal, encontraram em seu bolso um saco plástico, que tinha em seu interior uma espécie de pó e, segundo o próprio acusado Kauan, tratava-se da droga sintética conhecida como "MDMA". Ao ser indagado, o acusado Kauan informou residir naquela casa onde fora abordado em frente e que no interior do imóvel havia mais drogas, inclusive em estado de preparação. Diante das informações, realizaram vistoria domiciliar e encontraram um "laboratório" utilizado para a produção de maconha, além de várias mudas da planta acondicionadas em vasos e plantadas no quintal da moradia. No quarto da residência, os policiais encontraram uma estufa grande, improvisada, no interior de um guarda-roupas, com várias mudas de maconha já em ponto de secagem. Ainda, em uma cômoda, havia um saco plástico contendo maconha já pronta para a venda. Enquanto vistoriavam o imóvel, adentrou na casa o ora acusado Wilson, que, revistado na ocasião, tinha consigo 20 (vinte) comprimidos de "ecstasy", além da quantia de R\$ 90,00 (noventa reais). O acusado Wilson mencionou que teria vindo da cidade de São Paulo para fazer uma entrega daquelas drogas ao acusado Kauan, o qual as encomendara via WhatsApp. No veículo modelo Ford/Fiesta, de propriedade do acusado Wilson, os policiais apreenderam mais 04 (quatro) comprimidos de "ecstasy". Diante dos fatos, a perícia foi acionada e compareceu junto ao local juntamente com a autoridade policial. Além das drogas apreendidas na casa do réu Kauan, também

foram apreendidas duas balanças de precisão, um temporizador utilizado na estufa, um caderno com anotações típicas do comércio ilícito, a quantia de R\$268,00 (duzentos e sessenta e oito reais), uma câmera fotográfica e um cooktop (fls. 12 e 17).

Em juízo, às perguntas da Defesa do acusado Wilson, o policial militar Maurício respondeu que, a princípio, a denúncia dizia respeito apenas a Kauan. Houve apoio de outras viaturas na diligência. No momento em que Wilson adentrou a residência de Kauan, somente a viatura dos policiais Maurício e Rodrigo estavam no local. As demais estavam no final da rua, sem saber o policial precisar a que distância. A ocorrência foi no período diurno. Não chegaram a verificar os aparelhos de telefonia celular dos acusados. Wilson apresentou nervosismo ao adentrar a residência. Às perguntas da Defesa do réu Kauan, Maurício alegou que o ponto em que fica a residência de Kauan não é conhecido pelo tráfico de drogas. O laboratório para a produção de drogas era profissional, a seu ver, com objetos amadores, a indicar que Kauan sabia o que estava fazendo. Todo o quarto era utilizado para a produção e cultivo das drogas. No dia da abordagem, Kauan confessou que tinha mais drogas em sua residência e que fazia a produção desta "maconha pura". O réu Kauan disse que fazia o uso deste tipo de droga, mas também vendia, pois se tratava de um tipo de droga rentável, por ser mais pura.

O policial militar Rodrigo, em juízo, acrescentou que a casa do réu Kauan é sem muro, e as viaturas estavam na parte de cima da casa. Deste modo, Wilson adentrou o imóvel pela frente, sem perceber a presença de policiais no local. A princípio, Wilson não falou nada. Mas como foi encontrada droga em seu poder, ele confirmou que agia com o réu Kauan, e havia troca de mensagens por WhatsApp entre eles. O público deles eram pessoas que podem pagar mais caro por drogas. O valor de cada comprimido de ecstasy era alto.

As testemunhas arroladas pela Defesa do acusado Wilson, conforme termo de declarações de fls. 434 e 447, Rafael e Leandro, afirmaram ser o acusado boa pessoa, sem envolvimento com o tráfico de drogas.

Em que pese as declarações das testemunhas arroladas pelas Defesas dos acusados, não foi produzida prova hábil a desconstituir as declarações dos policiais, registradas pelas imagens de fls. 30/63.

Os relatos uníssomos dos policiais indicando a apreensão de significativa quantidade de drogas, de tipos diversos, no interior da residência do réu Kauan, onde também chegara o acusado Wilson, com mais drogas, tendo havido também apreensão de dinheiro, balança de precisão, estufa para o preparo de droga, agenda contendo anotações do comércio ilícito, comprovam o tráfico descrito na denúncia, tornando inevitável um desate condenatório em relação a ambos os acusados.

As versões apresentadas pelos réus não merecem credibilidade, tendo sido contrariada pela palavra dos policiais que efetuaram a prisão e não tinham motivos para incriminá-los injustamente.

Não há se falar em desclassificação das condutas dos acusados para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas, eis que a quantidade e diversidade de drogas apreendidas não permitem essa afirmação, mormente porque na casa de Wilson havia uma espécie de laboratório para preparo de entorpecentes com vários petrechos, a indicar que a droga era destinada à venda. Havia no local, além das plantações de maconha, estufa para secagem, maconha já acondicionada em saco plástico, além de drogas sintéticas, tanto com Wilson quanto com Kaun, sem falar em balança de precisão, caderno com anotações e numerário trocado.

Não há se falar em flagrante preparado com relação ao réu Wilson. Os policiais militares em momento algum disseram que a residência de Kauan tinha uma entrada pelos fundos. Apenas reforçaram que a viatura policial não estava em frente à casa de Kauan, o que também foi dito pelo acusado Wilson em seu interrogatório judicial. Segundo os policiais e o próprio acusado Wilson, ele chegou à residência em certo momento e se deparou com a polícia no imóvel. Os policiais mencionaram que, a princípio, Wilson negou qualquer envolvimento com o acusado Kauan mas, após um tempo, confirmou que também vendia droga com ele. Tampouco a alegada quebra de sigilo telefônico restou comprovada.

Os minuciosos relatos trazidos pelos agentes demonstram que o acusado Kauan, após

denúncia anônima de tráfico no local, fora visto em frente à sua residência, tendo franqueado a entrada dos policiais após ser surpreendido com drogas. No imóvel, foram encontrados os entorpecentes, bem como um plantio de maconha para posterior venda. Com a entrada na residência foram apreendidas as drogas, além de dinheiro, estufa, balança de precisão, caderno de anotações típicas do tráfico de drogas, e dinheiro.

Note-se que o réu Wilson, que posteriormente chegou ao local, admitiu também aos policiais que ali estava para a comercialização de drogas. Possuía drogas em seu poder e também no interior de seu veículo, além de certa quantia em dinheiro. Ainda, a grande quantidade de droga apreendida, além de materiais para o preparo e venda de maconha (estufa e temporizador) e balança de precisão, demonstra o estreito envolvimento do réu Kauan com o tráfico já que nenhum iniciante nesta atividade criminosa receberia tamanha quantidade para guardar ou apenas consumir. Por conseguinte, Kauan não pode ser considerado traficante eventual ou de pequeno porte, razão pela qual deve ser afastado o tráfico privilegiado. Em relação a Wilson, considerando que não demonstrada sua relação com as drogas encontradas com o corréu e na residência, possível o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Contudo, não há se falar em incidência da infração penal prevista no artigo 33, § 1.º, inciso II, da Lei de Drogas, como descrito na denúncia.

Isso porque esta infração penal tem natureza eminentemente subsidiária frente ao delito previsto no artigo 33, caput, da mesma Lei especial, pois a apreensão de plantas que constituem matéria-prima para a preparação de drogas deu-se no mesmo contexto fático do crime de tráfico acima descrito, de modo a ser considerado meio necessário para a sua concretização.

Desta feita, de se aplicar o princípio da consunção com relação ao crime previsto no artigo 33, § 1.º, inciso II da Lei de Drogas.

Demonstrada, assim, as responsabilidades criminais dos acusados, passo a dosar as penas a serem impostas.

Os acusados são primários, conforme se depreende de suas folhas de antecedentes (fls. 73/75 - réu Kauan; fls. 312/314 - réu Wilson).

1) Com relação ao réu Kauan, contudo, diante da expressiva quantidade e diversidade de droga apreendida (quase meio quilo de drogas), juntamente com petrechos de tráfico, tendo sua residência voltada para a preparação de maconha, o que indica crime em pelo menos média escala, com maior risco à coletividade, elevo sua pena-base em 1/5, fixando-a inicialmente em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Ante sua menoridade relativa, reduzo a pena em 1/6, retornando-a ao mínimo legal.

Apesar de ser primário, deixo de aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4.º, da Lei 11.343/06, porquanto a quantidade e diversidade de droga, estufa, anotações apreendidas revelam que o réu estava se dedicando a esta atividade criminosa, na qualidade de produtor e distribuidor, e não pode ser considerado traficante eventual ou de pequeno porte. Isto porque nenhum traficante ocasional teria tamanha quantidade de plantações de maconha, sendo certo, ainda, que não provou qualquer outra ocupação lícita.

2) Quanto ao acusado Wilson, fixo sua pena-base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, no piso.

Com fulcro no artigo 33, parágrafo 4.º, da Lei 11.343/06, não havendo notícia de que integre organização criminosa ou se dedique à atividade criminosa, pois nenhuma prova foi feita neste sentido, reduzo sua pena do tráfico em 2/3, fixando-a definitivamente em 01 ano e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias-multa, no piso.

Anoto que a redução prevista no dispositivo não é inconstitucional, pois, da mesma forma que a Lei Maior facultou ao legislador ordinário agravar a pena de crimes que considerava hediondos ou graves, retirando de seus autores benefícios que poderiam ser concedidos a autores de delitos de outras espécies, igualmente graves, também permitiu que a reprimenda fosse diminuída em razão de circunstâncias que indicassem o menor potencial lesivoda conduta do agente.

A Constituição Federal, no seu artigo 5.º, XLVI, trata da individualização da pena. Ao distinguir o pequeno traficante dos demais, a norma infraconstitucional

apenas atendeu à diretriz da Carta Magna, não havendo qualquer ofensa a ela. Neste sentido leciona José Celso de Mello Filho ao tratar do citado dispositivo: "a exigência de individualização da pena, que é de índole constitucional, deve ser analisada sob três aspectos principais: a) o da individualização legal, operada pelo legislador, por meio da abstrata cominação das sanções em função da maior ou menor gravidade objetiva do ilícito; b) o da individualização judicial, efetuado pelo magistrado, por meio da sentença, no momento da aplicação concreta da sanção penal; c) o da individualização administrativa, concretizada na fase de execução da pena, ensejando-se, dessa forma, nos estabelecimentos prisionais, um tratamento específico para cada condenado" (Constituição Federal Anotada, 2ª ed. Saraiva 1986).

Não havendo prova de envolvimento anterior do réu Wilson com atividade ou organização criminosa, inviável o afastamento da mitigação da pena.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR os acusados KAUAN EDUARDO VILELA RODRIGUES e WILSON MORENO JUNIOR ao cumprimento das penas de 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, no piso; e 01 ano e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias-multa, no piso, respectivamente, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. ABSOLVO o acusado KAUAN EDUARDO VILELA RODRIGUES da infração prevista no artigo 33, § 1.º, inciso II da Lei de Drogas, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal.

O réu Kauan não faz jus a penas substitutivas e tampouco ao sursis pelo tempo de pena imposto.

Faz jus, contudo, ao cumprimento da pena no regime semi-aberto pela primariedade e tempo de pena imposto.

Para o réu Wilson, o Colendo Supremo Tribunal Federal, no HC 118.533, pacificou o entendimento que o tráfico privilegiado não deve ser considerado crime de natureza hedionda.

Diante disso, revisando o entendimento adotado por esta Magistrada há muitos anos, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e observados os critérios de individualização da pena, vez que as circunstâncias judiciais são favoráveis, fixo o regime inicial aberto, consoante disposto no artigo 33, § 3.º, do Código Penal. Outrossim, preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, incisos I a III, e artigo 77, caput, inciso III, do Código Penal, substituo sua pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo das penas substituídas, em entidade a ser definida pelo juízo da execução, além da prestação pecuniária, consistente no pagamento de um salário mínimo em favor de entidade também a ser definida pelo juízo da execução.

Os réus poderão apelar em liberdade, pois não deram motivos para a revogação do benefício da liberdade provisória concedida, bem como pela pena a eles imposta.

Após o trânsito em julgado, proceda a Serventia as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

No tocante ao pedido da Defesa do acusado Wilson, DEFIRO o pedido de restituição do veículo e celular apreendidos, eis que não demonstraram relação com os delitos descritos nos autos. Oficie-se.

Declaro o perdimento de bens e valores apreendidos em favor da FUNAD, após o trânsito em julgado.

Sentença registrada eletronicamente.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

São José dos Campos, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA